



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-68167244- -APN-DR#CNDC - OPI 337

VISTO el Expediente N° EX-2020-68167244- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N.º 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de la Ley N° 27.442.

Que la operación traída a consulta consiste en un acuerdo mediante el cual la firma WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L. adquirirá de la firma NEWSAN S.A. ciertos hornos microondas que producirá esta última, de conformidad con ciertas especificaciones técnicas acordadas entre ambas partes.

Que, en contraprestación por la fabricación de dichos productos, se acordó un precio en función de determinadas variables que conforman los costos de producción, y que podrán ser revisados por la firma NEWSAN S.A. periódicamente.

Que la duración del acuerdo se estipuló en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) meses, pudiendo cualquiera de los contratantes rescindir sin causa, previa notificación con una antelación mínima de CIENTO OCHENTA (180) días.

Que la operación traída a consulta se instrumentó mediante una oferta realizada por la firma NEWSAN S.A. a la firma WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L. el día 14 de julio de 2020.

Que dicha oferta fue aceptada por la firma WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L., produciéndose el cierre de la operación el día 16 de julio de 2020.

Que la operación sometida a consulta no se encuentra encuadrada en los términos del Artículo 7° de la Ley N°

27.442 y, en consecuencia, no está sujeta a la obligación de notificación dispuesta en el Artículo 9° de la mencionada ley.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido el Dictamen de fecha 2 de diciembre de 2020, correspondiente a la “OPI 337”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional sugirió hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de la referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente medida.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° de Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a los consultantes que la operación traída a consulta consistente en un acuerdo mediante el cual la firma WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L. adquirirá de la firma NEWSAN S.A. ciertos hornos microondas que producirá esta última, no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación dispuesta en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 2 de diciembre 2020, correspondiente a la “OPI 337” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, identificados como Anexo IF-2020-83945737-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 337 - Dictamen

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por Expediente EX-2020-68167244- -APN-DR#CNDC caratulado: "WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L. S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10° DE LA LEY 27.442 (OPI 337)", e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10° de la Ley N.° 27.442 y su decreto reglamentario N.° 480/2018.

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD.

1. WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L. (en adelante, "WHL"), es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, que comercializa grandes electrodomésticos¹ y que cuenta con una planta industrial ubicada en la localidad de La Tablada, Provincia de Buenos Aires.

2. NEWSAN S.A., (en adelante, "NS") es una empresa de origen nacional dedicada fundamentalmente a la fabricación, comercialización y distribución de pequeños y grandes electrodomésticos. NS comercializa los electrodomésticos que produce bajo las marcas NOBLEX, ATMA, PHILCO y SANSEI, y a su vez, cuenta con licencias de las marcas SANYO, JVC, MOTOROLA, LG Y SHARP. Posee cinco plantas industriales y dos centros logísticos en el país².

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA.

3. La operación que se consulta consiste en un acuerdo mediante el cual WHL adquirirá de NS ciertos hornos microondas (en adelante los "PRODUCTOS") que producirá esta última, de conformidad con ciertas especificaciones técnicas acordadas entre ambas partes.

4. Se utilizarán las patentes y diseños industriales provistos por WHL, y los PRODUCTOS serán fabricados en la Planta N° 5 de NS ubicada en Tierra del Fuego.

5. Los PRODUCTOS se entregarán a WHL con las marcas, etiquetas, códigos de barra y números de serie, de acuerdo a un plan de entrega y proyecciones mensuales pre-acordado entre NS y WHL (en adelante las "Partes").

6. En contraprestación por la fabricación de los PRODUCTOS, se estipuló un precio determinado en función de determinadas variables que conforman los costos de producción, y que podrán ser revisados por NS periódicamente.

7. Los derechos sobre el diseño industrial y formato y/o cualquier otro derecho intelectual vinculado a los productos objeto del Acuerdo son de titularidad de WHL. Los PRODUCTOS a su vez, serán distinguidos con las marcas “Whirlpool” u otra marca que WHL informe oportunamente y se solicitarán de acuerdo a ciertas proyecciones realizadas en forma anual, que podrán actualizarse en forma mensual.

8. Finalizado el acuerdo, NS deberá devolver o destruir, según instrucciones de WHL, todos los materiales que contengan marcas de propiedad de esta última, comprometiéndose NS a no utilizar ninguna de las marcas en cuestión ni cualquiera similar ni a instruir a un tercero a hacerlo.

9. La duración del acuerdo se estipuló en un plazo de 48 meses, pudiendo cualquiera de las Partes rescindir sin causa, previa notificación con una antelación mínima de 180 días de anticipación. También, el contrato, podrá ser rescindido por incumplimiento de una parte, previa intimación fehaciente por el plazo de 45 días corridos para que el incumplimiento sea subsanado.

10. No se han acordado compromisos de no competencia.

11. La operación traída a consulta se instrumentó mediante una oferta realizada por NS a WHL el día 14 de julio de 2020, produciéndose el cierre de la operación con la aceptación de la Oferta por parte de WHL, el día 16 de julio de 2020.

III. PROCEDIMIENTO.

12. El día 17 de julio de 2020, debido a la emergencia sanitaria nacional establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 260/2020 en razón de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19 y de la suspensión de todos los plazos procesales de la Ley N.º 25.156 y N.º 27.442, conforme la Resolución SCI N.º 260, se presentó mediante correo electrónico ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) el apoderado de la firma WHL, solicitando opinión Consultiva con respecto a si la operación precedentemente mencionada, encuadraría dentro de los términos del artículo 10 de la Ley N.º 27.442.

13. El día 01 de octubre de 2020, esta Comisión Nacional efectuó, a través de correo electrónico, un requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto N.º 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N.º 26/2006 no comenzará a correr hasta tanto no se dé cumplimiento a lo solicitado y que se reanuden los plazos suspendidos conforme la Resolución SCI N.º 260. A su vez se les solicitó que atento a lo estipulado en el artículo 1 de la Resolución SCI N.º 231/2020, realicen el pase de las actuaciones a la tramitación a través de la plataforma Trámites a Distancia – TAD.

14. Con fecha 15 de octubre de 2020 el apoderado de WHL efectuó una presentación con relación al requerimiento efectuado oportunamente por esta Comisión Nacional e informando que con fecha 9 de octubre del corriente se dio curso a lo solicitado, realizando las gestiones necesarias a efectos de la tramitación de las presentes actuaciones a través de la plataforma Trámites a Distancia – TAD.

15. Con fecha 19 de octubre de 2020, el apoderado de WHL rectifica el “Anexo I – Poder” acompañado en la presentación de fecha 14 de octubre, debido a que por un error se cargó en TAD la documentación equivocada, adjuntando el poder correspondiente.

16. El día 29 de octubre del corriente año, esta Comisión Nacional informó que se encuentra habilitado el expediente EX-2020-68167244-APN-DR#CNDC caratulado “OPI 337. - WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442” a través del cual proseguirá el trámite de la opinión consultiva solicitada.

17. Finalmente, con fecha 17 de noviembre de 2020, se completó la información solicitada.

IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PLANTEADA.

18. Habiendo descrito en los apartados anteriores las principales características de la operación consultada, corresponde en esta instancia que esta Comisión Nacional se expida sobre la misma.
19. En principio, cabe recordar que, como consecuencia de la operación traída a consulta, WHL y NS celebraron un acuerdo por término de cuarenta y ocho meses, por medio del cual WHL adquirirá ciertos hornos microondas que producirá NS de conformidad con ciertas especificaciones acordadas entre las Partes, sin régimen de exclusividad.
20. Ello así, las Partes informan que ambas conservan total autonomía para continuar con sus negocios en la forma y con la habitualidad que lo han venido haciendo, ya que el acuerdo no establece ningún tipo de exclusividad ni limitación a la producción de NS, tampoco compromete la productividad de la planta. Las Partes mantendrán sus propios negocios en funcionamiento individual e independientemente de la otra parte, con su propia clientela, estrategia de negocios, sistemas de control y ventas.
21. Respecto a lo mencionado precedentemente, las partes aclaran WHL puede fabricar los productos de forma directa en sus propias instalaciones, o encargar a un tercero la fabricación de dichos productos, según lo estime conveniente, y sin necesidad de dar aviso o solicitar autorización de ningún tipo. De la misma manera NEWSAN podría fabricar productos propios o de terceros sin requerirse notificación o autorización por parte de WHL.
22. Por otra parte, se menciona que no existirá intercambio de información sensible desde el punto de vista comercial que permita a cualquiera de las “Partes” conocer estrategias comerciales futuras, precios de venta, planes de negocios o cualquier otra información de la otra, que permita establecer algún tipo de actividad en forma coordinada.
23. Se informa también que no existe otorgamiento de un derecho o facultad de adquirir los negocios de la otra parte, opción de compra de sus activos, ni un aumento unilateral de las cantidades de producción comprometida que pudiera resultar eventualmente en un futuro cambio de control.
24. Asimismo, las partes consultantes agregan que el Contrato de Suministro no prevé injerencia alguna por parte de NEWSAN en las políticas o estrategias de comercialización de WHL, siendo un mero fabricante por cuenta y orden de WHL, de aquellos productos que éste último le indique de conformidad con ciertos costos de producción referenciales que son actualizados periódicamente.
25. En este sentido corresponde mencionar que el artículo 7° de la Ley N.º 27.442 establece que habrá concentración económica, es decir toma de control, de una o varias empresas, cuando a través de cualquier acuerdo o acto se transfiera de forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o se le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinarias de una empresa.
26. Esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene dicho que debe entenderse por activos, a todos aquellos que posibiliten el desarrollo de una o varias actividades, a las que se puedan atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originado en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica.
27. A su vez, también ha expresado que, a fin de establecer la existencia de una toma de control se debe atender al “principio de realidad económica”, por lo que la celebración de determinados contratos, como así también el plazo de vigencia de los mismos, requiere de un análisis caso por caso³. Por lo tanto, dadas las características del contrato, esta CNDC considera que no corresponde ser notificado.
28. Esta Comisión Nacional ha resuelto anteriormente, en la Opinión Consultiva N.º 904 de fecha 15 de septiembre de 2011⁴, que la celebración de un contrato de fação sin régimen de exclusividad y sin opción de compra de las instalaciones, no transfiere un activo que constituya una toma de control de la empresa, de esta manera no corresponde su notificación en los términos del art. 8 de la Ley N.º 25.156 por entender que la misma no se encuadraba en lo normado por el art. 6 inc. d) de la Ley N.º 25.156. En el mismo sentido, en el caso de autos, también se trata de una simple relación contractual de suministro que no involucraría una concentración económica en los términos del artículo 10° de la Ley N.º

27.442.

29. Por ello, esta Comisión Nacional entiende que la operación que origina la presente consulta, respecto del acuerdo por el plazo de 48 (cuarenta y ocho) meses no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley N.º 27.442.

V. CONCLUSIÓN.

30. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley N.º 27.442. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

¹ Entre sus líneas de productos se encuentran aires acondicionados, aspiradoras, heladeras, congeladores, cocinas, microondas, anafes, hornos, campanas, lavarropas, secarropas y lavavajillas. Dichos productos se comercializan bajo las marcas “Whirlpool”, “Eslabón de lujo”, “Ariston” e “Indesit”.

² En la provincia de Tierra del Fuego se centraliza la mayor parte de sus operaciones, con cinco plantas productivas y un centro logístico ocupando una superficie aproximada de 70.000 m².

³ Opinión Consultiva N° 177 (Caratulada: *“YPF S.A. Y PARAFINA DEL PLATA S.A.C.I. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI N° 177)”.

⁴ CNDC Opinión Consultiva No. 904 de fecha 15 de septiembre de 2011. Expediente N° S01:0390011/2010 caratulado: “YPF S.A. Y ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI N° 196)”.